

次の【事例】の甲に対する刑法の適用に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

甲は、日本国内に居住するA国民である。

甲は、B国を訪れた際、同国内に居住する日本国民V1並びに日本国内に居住する日本国民V2及び同V3を殺害しようと考え、B国において、毒入りの酒（以下「毒入酒」という。）をV1方、V2方及びV3方に向けてそれぞれ発送し、その後日本に帰国した。

V1宛ての毒入酒は、V1方に到達し、これをB国内で飲酒したV1及びその友人であるB国民V4は、それぞれ、同国内で薬物中毒により死亡した。

V2宛ての毒入酒は、甲が発送手続の際、誤ってV2と同姓の日本国民V5の住所地を記載したことから、日本国内のV5方に配達され、V5は、V2宛ての配達物であることに気が付いたが、しばらく保管して誰からも連絡がなかったら自分で飲酒しようと思い、これを自宅に保管していた。

V3宛ての毒入酒は、V3方に到達したが、配送途中の事故により、瓶が割れ、到達時には毒入酒がすべて無くなっていたことから、V3は、これを飲酒することができなかった。

【記述】

1. V1に対する行為について刑法（殺人罪）が適用される。
2. V2に対する行為について刑法（殺人未遂罪）が適用される。
3. V3に対する行為について刑法（殺人未遂罪）が適用される。
4. V4に対する行為について刑法（殺人罪）が適用される。
5. V5に対する行為について刑法（殺人未遂罪）が適用される。

（参照条文）刑法

第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 （略）

二 第199条（殺人）の罪及びその未遂罪

三～六 （略）

1 正しい

3条の2第2号。日本国外において日本国民に対して、殺人罪又は殺人未遂罪を犯した日本国民以外の者には刑法が適用される。その趣旨は、国際的な人の移動の日常化に伴い、日本国外において日本国民が犯罪の被害にあう機会が増えたことから、重大な犯罪に限り、自国民が犯罪の被害にあった場合に刑法を適用する点にある（保護主義）。本記述で、甲はA国民であるが、B国内で日本国民V1を殺害しようと考えV1方へ毒入酒を発送し、結果B国内でV1は薬物中毒により死亡した。よって、B国内という「日本国外」において「日本国民」V1に対して、A国民という「日本国民以外の者」である甲が「殺人罪」を犯したので、甲のV1に対する行為について刑法（殺人罪）が適用される。

2 誤っている

1条1項、43条本文。大判大7.11.16（百選165事件）。「日本国内において罪を犯した」（1条1項）とは、構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われた場合、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合を指す。そこで、本記述で、甲が毒入酒を発送したV2方は日本国内であるので、甲にV2に対する殺人罪の実行の着手が認められるならば、殺人未遂罪という結果が日本国内で発生したとして、甲は「日本国内において罪を犯した」といえる。判例は、Xが殺害する目的で毒薬混入の砂糖をYに郵送した事案において、毒薬混入の砂糖はYがこれを受領した時にY又はその家族の食用しう状態の下に置かれたので、既に毒殺行為の着手があるといえるとしている。つまり、毒物の受領時点を毒殺行為の実行の着手の基準時としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、受領の時点において、死亡という殺人罪の構成要件の結果発生の危険を具体的に惹起したということを挙げている。本記述で、甲の発送した毒入酒はV2方に届いていないので、甲はV2の死亡という結果発生の危険を具体的に惹起しておらず、甲に毒殺行為の実行の着手は認められない。よって、甲は「日本国内において罪を犯した」といえないので、甲のV2に対する行為について刑法（殺人未遂罪）は適用されない。

3 誤っている

1条1項、43条本文。大判大7.11.16（百選165事件）。本記述で、甲の発送した毒入酒は、V3方への到達時点においてすべて無くなっているので、甲はV3の死亡という結果発生の危険を具体的に惹起しておらず、甲に毒殺行為の実行の着手は認められない。よって、甲は「日本国内において罪を犯した」（1条1項）といえないので、甲のV3に対する行為について刑法（殺人未遂罪）は適用されない。

4 誤っている

1条1項、2条、3条の2。甲が「日本国内において罪を犯した」（1条1項）といえるのは、構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われた場合、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合である。本記述で、V1方への毒入酒の発送という行為がされた場所及びV4の死亡という結果が発生した場所は日本国外であるB国内であるので、甲が「日本国内において罪を犯した」とはいえない。次に、すべての国外犯に対して刑法が適用される保護主義は、殺人罪については適用されない（2条参照）。また、甲はA国民という日本国民外の国外犯であるが、日本国民外の国外犯について殺人罪が適用されるのは、「日本国民に対して」殺人罪を犯した場合である（3条の2第2号）。本記述で、甲が殺害したのは「日本国民」外のB国民V4であるので、甲が「日本

国民に対して」殺人罪を犯したとはいえない。よって、甲のV4に対する行為について刑法（殺人罪）は適用されない。

5 正しい

1条1項、43条本文、38条1項。大判大7.11.16（百選I65事件）、最判昭53.7.28（百選I42事件）。まず、本記述では、甲は日本国外のB国から、日本国内のV2方に対して毒入酒を発送したが、V5方に毒入酒は配達されており、V5の飲用しうる状態の下に置かれたので、既に毒殺行為の実行の着手があるといえる。次に、甲はV2を殺害するつもりであったにもかかわらず、毒入酒はV5に配達されたといういわゆる方法の錯誤の点につき、判例（最判昭53.7.28）は、XがYに対してびょうを発射したが、Yの身体を貫通したびょうがたまたまZにも命中した事案において、「人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである」としている。その理由として、判例は、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りるものと解すべきである」ということを挙げている。したがって、本記述では、甲はV2を殺害する意思のもと毒入酒をV2方に発送し、毒入酒はV5に配達されたが、甲の認識した事実と現実に発生した事実は199条の「人を殺す」という範囲内において一致しているので、甲にV5に対する殺人の故意があるといえる。以上より、甲にV5に対する殺人罪の実行の着手が認められるが、V5の死亡という結果は発生していないので、殺人未遂罪という結果が日本国内において発生したとして、甲は「日本国内において罪を犯した」といえる。よって、甲のV5に対する行為について刑法（殺人未遂罪）が適用される。